

1500290-33.2021.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500290-33.2021.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-33.2021.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2302215/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 21235437 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 3212/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2302215 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2302215 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 3212/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 082/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEZER HENRIQUE CAMPOS GREGÓRIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ELIEZER HENRIQUE CAMPOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", e art. 35, "caput", c.c. art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, em dia e horário

indeterminados, porém anterior à tarde de 05 de novembro de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Muntaha Barcheti Urrêa Lopes, número 131, Jardim Brasil, neste município e Comarca de Avaré, associou-se com o adolescente Victor Hugo Pechim Lutfi, "PAULO" e "JOÃOZINHO", pendentes de identificação, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06. Consta, ainda, dos presentes autos que na tarde de 05 de novembro de 2021, por volta das 16 horas, na Avenida Muntaha Barcheti Urrêa Lopes, número 131, Jardim Brasil, neste município e Comarca de Avaré, com o envolvimento do adolescente Victor Hugo Pechim Lutfi, tinha em depósito, para entrega ao consumo de terceiros, 19 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 24,0 gramas (vinte e quatro gramas) e outras 20 (vinte) porções de cocaína, com peso de 15,60 gramas (quinze gramas e sessenta centigramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 13/17, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/130. Por decisão proferida em 06 de novembro de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 86/88). Mandado de prisão cumprido a fls. 99/100. A denúncia foi oferecida em 03 de dezembro de 2021 e o réu, notificado a fls. 152, ofereceu Resposta à Acusação a fls. 157. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 161/163). Em audiência, foram inquiridas 03 testemunhas de acusação e o réu interrogado (fls. 207/208 e gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 212/217). A douta Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito para o crime de porte de drogas e, em caso de eventual condenação, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos, além do direito de recorrer em liberdade (fls. 221/237).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "havia notícias do envolvimento do denunciado com a prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para tanto, o denunciado, o adolescente e JOÃOZINHO vendiam drogas no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, certo que, na ausência deles, ajustaram com um terceiro, PAULO, residente em imóvel vizinho, o fornecimento das drogas aos usuários. Em razão de tais informações e considerando a movimentação atípica de pessoas, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos número 1504105-86.2021.8.26.0073, a DISE Avaré se dirigiu até a residência, na qual se encontravam ELIEZER e Victor Hugo. O denunciado tinha em depósito, em um tênis de sua propriedade, dezenove porções de maconha. Ainda, no imóvel foram encontradas outras vinte porções de cocaína no quintal, em uma área coberta por grama. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro".

Encerrada a instrução processual, à luz da prova produzida, a denúncia procede parcialmente.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 03/04, boletim de ocorrência a fls. 05/08, auto de exibição e apreensão a fls. 11, laudo de constatação provisória a fls. 13/17, laudo toxicológico a fls. 107/111, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Diego do Amaral, policial civil, sob o crivo do contraditório, relatou "que havia notícias de tráfico no local, motivo pelo qual a equipe realizou campana. Disse que avistaram movimentação atípica de pessoas, momento em que avistaram Joãozinho, Vitor Hugo e Paulo no local. Falou que sabiam de fornecedores de drogas do tráfico local e que prenderam alguns indivíduos

naquela localidade, mas substituíram os agentes para a continuidade da atividade. Falou que em cumprimento do mandado de busca e apreensão surpreenderam o réu e o adolescente dormindo no imóvel e que o réu foi um dos que correu no flagrante anterior. Relatou que encontraram porções de maconha em um tênis branco de propriedade do acusado e que, nos fundos do imóvel, encontraram uma sacola no meio da grama com mais drogas".

A testemunha de acusação Edson Barca, policial civil, em juízo, reprisou a assertiva de seu colega. Acrescentou que "as 19 porções de maconha estavam escondidas num tênis branco e que o réu admitiu lhe pertencer. Falou que os 20 eppendorfs de cocaína estavam no meio da grama, no quintal da casa. Informou que o local dos fatos foi monitorado durante vários dias pelos policiais e que verificaram a movimentação intensa de pessoa no local".

O adolescente Victor Hugo, em juízo, confirmou "que estava no local dos fatos no momento da abordagem. Disse que o imóvel é abandonado e que a droga no tênis era de sua propriedade. Relatou que no procedimento da infância não assumiu que a droga era sua. Disse que comprou as drogas na Concha Acústica e que não conhece Paulo e Joãozinho. Falou que era a primeira vez em que ia até a casa e que, no local, só havia um par de tênis. Falou que estava descalço".

O réu Eliezer Henrique, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que estava no imóvel junto com mulheres e que a droga localizada não era sua. Afirmou que o tênis branco no qual a maconha estava escondida era de sua propriedade".

Com efeito, a negativa de autoria do réu nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais, além da prova da materialidade.

Nesse contexto, a versão do acusado além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que ele nada produziu, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação, não havendo, pois, qualquer razão para desacreditá-los. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.). Assim, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, das campanhas efetivadas pelos policiais observando a movimentação alta de pessoas no local, pela quantidade de droga apreendida (19 porções de maconha e 20 eppendorfs de cocaína), bem como do modo pelo qual estava acondicionada.

Ressalte-se, ainda, que conquanto o adolescente Victor tenha afirmado que a droga era de sua propriedade, nos autos do processo infracional nº 1500289-48.2021.8.26.0574 manteve-se em silêncio, restando, pois, evidente, que aqui buscar assumir a responsabilidade para isentar o réu Eliezer.

Todavia, a dinâmica dos fatos foi narrada de forma uniforme e coesa pelos policiais que participaram da ocorrência, não havendo qualquer motivo para afastar sua credibilidade. Restou apurado que os policiais informaram que o imóvel era utilizado para a comercialização de drogas, sendo que inclusive já havia sido alvo de ação policial que culminou com prisão e apreensão de drogas. Assim, é que as investigações prosseguiram com o fito de apurar outros envolvidos na associação para o tráfico de drogas. E, após constatada a traficância praticada pelo Eliezer, encontraram 19 porções de maconha, no interior de um tênis de cor branca, o qual o réu admitiu lhe pertencer. Depois, localizaram ainda 20 eppendorfs contendo droga cocaína, que se encontravam ocultas nos fundos do imóvel, em meios à grama alta. Os policiais relataram que o local fora monitorado por dias e horários diversos, e nas ocasiões fora visualizado Victor Hugo e o réu pelo local. Durante o monitoramento

outras pessoas não identificadas frequentavam o imóvel que se trata de um "ponto de drogas". Durante as diligências realizadas não foi possível abordagem de pessoas, uma vez que a equipe encontrava-se reduzida e não possuía autorização judicial para incursão no imóvel, uma vez que os informes apontavam a presença de drogas no interior deste.

Assim é, que os depoimentos prestados pelas testemunhas, da fase inquisitiva à judicial, foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar o réu, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De igual modo, a causa especial de aumento descrita no inciso VI (envolver adolescente) do art. 40 da lei de Drogas está devidamente comprovada nos autos tanto que, como já dito anteriormente, o adolescente respondeu a processo infracional tendo-lhe sido aplicada a medida sócio educativa de Liberdade Assistida. Neste ínterim, ressalte-se ser absolutamente fantasiosa as alegações do menor no sentido de que a droga era de sua propriedade evidenciando, apenas, uma tentativa de eximir o réu de sua culpa.

Desta feita, merece reprovação maior a conduta perpetrada pelo réu, eis que, em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral, utilizou-se do seu relacionamento com a adolescente, disseminando droga em sua vida e atrelando-o ao comércio espúrio de entorpecentes em detrimento de uma vida correta, pautada pelos estudos e trabalho honesto, mostrando a ele lucro fácil na tentativa de lhe desvirtuar do caminho que deve percorrer os cidadãos de bem.

Por outro lado, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não há prova acerca do suposto "animus" associativo entre o réu e os adolescentes, notadamente pelo fato de que o réu Eliezer estava há pouco tempo em liberdade. Nesse sentido vem ensinando a doutrina: "não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210). No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira *societas sceleris* que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743)."

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que o réu praticava o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu ELIEZER HENRIQUE CAMPOS GREGÓRIO, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, ABSOLVO o réu ELIEZER HENRIQUE CAMPOS GREGÓRIO da imputação no tocante ao delito do artigo 35 da lei de Drogas com fundamento no artigo 386, inciso VII, CPP. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls. 170/172) eis que os processos infracionais pelo qual respondeu (fls. 68) não possuem o condão de elevar a pena base. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, eis que a pena já fora fixado em seu patamar mínimo legal. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitativa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já

sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 86/88, podendo o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA